

1502133-26.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico, os antecedentes infracionais e criminais do réu e, ainda, o depoimento das testemunhas de, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502133-26.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502133-26.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241977/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 20061744 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2843/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2241977 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

EDVAN ALCANTARA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

EDVAN ALCANTARA DOS SANTOS qualificado às fls. 14, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (estado de calamidade pública), porque segundo narra a denúncia de fls. 01/03, no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 11h40min, na Rua Francisco Frizzo, altura do nº 200, bairro Jardim Rosa, cidade e comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 69,82g (sessenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas); 225 (duzentas e vinte e cinco) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 187,95g (cento e oitenta e sete gramas e noventa e cinco decigramas); e 76 (setenta e seis) porções

de crack, com peso líquido aproximado de 12,16g (doze gramas e dezesseis decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Às fls. 68/70 foi convertido o flagrante em prisão preventiva do acusado.

A decisão de fls. 94/95 adotou o rito ordinário e determinou a citação do réu.

O réu foi citado (fls. 124) e apresentou defesa prévia às fls.(136/138).

A decisão de fls. 125/126 designou audiência de instrução e debates que foi realizada por videoconferência em razão da Pandemia da Covid-19.

Em audiência de instrução houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 156/157, o réu foi interrogado (fls. 154/155), bem como ouvida uma testemunha (fls. 153). Em audiência em continuação, foi ouvida a segunda testemunha e o réu foi interrogado (fls. 187/188).

O Ministério Público, em alegações finais, pediu a procedência da ação penal.

Afirma que se os policiais quisessem fazer uma falsa afirmação, não teria sentido que eles confirmassem que havia uma pedra de crack no bolso do réu, bastando afirmar que toda droga estava na sacola. Quanto a dosimetria pede que sejam considerados os antecedentes e reincidência na primeira e segunda fase. Na terceira fase afirma inviável o §4º do artigo 33 da lei de drogas. Pede regime fechado.

A Defesa de Edvan Alcântara dos Santos apresentou alegações finais, pleiteando a improcedência da ação penal. Afirmar que o réu é usuário de droga e dependente químico, estando sob efeito do crack, já tendo comprometimento de sua capacidade volitiva e cognitiva. Pede absolvição pela fragilidade probatória pela contradição entre os policiais. Segundo porque o próprio policial informou que o réu estava visivelmente sob efeito de entorpecente. Afirmar que o tráfico não entregaria o entorpecente para indivíduo sob efeito de crack.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 13); laudo de constatação da droga (fls. 31/35); laudo pericial químico toxicológico (fls. 98/99); folha de antecedentes (fls. 110/116) e certidão de distribuição criminal (fls. 118/120); Laudo objetos (fls. 146/148).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro apreendido.

A testemunha WILLIAM SANTOS DUARTE foi ouvido na fase policial às fls. 08 a afirmou: "Estava em patrulha pelo local dos fatos, conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, ocasião que viu um indivíduo do sexo masculino, sem camisa, segurando uma sacola plástica. Foi feita a abordagem do referido indivíduo, o qual foi identificado como EDVAN ALCANTARA DOS SANTOS. Dentro da sacola que EDVAN segurava havia 225 invólucros contendo substância semelhante a cocaína, 76 unidades de substância semelhante a crack e 48 unidades de substância semelhante a maconha. Dentro da sacola também havia R\$ 58,00 e 1 aparelho celular. Em busca pessoal foi encontrada uma pedra de crack no bolso da bermuda de EDVAN. Diante dos fatos, trouxe EDVAN até esta delegacia para as providências de polícia judiciária". Em juízo: que se recorda que apenas o réu estava no local, em local conhecimento por ser ponto de venda de droga; que o réu conseguia visualizar a viatura, tendo tentado fuga; que não se recorda se o réu estava sob efeito de entorpecente; que foi localizada a sacola com entorpecente e no bolso havia uma pedra de crack; que os valores estavam na sacola; que não viu ninguém saindo do local com a aproximação da viatura; que o réu fugiu quando foi abordado; que não conhecia o réu antes dos fatos; que o réu afirmou que o entorpecente não eram dele, mas não afirmou de quem era ou deu explicação.

A testemunha JOSE FREIRE DO NASCIMENTO foi ouvida na fase de inquérito às fls. 09, a afirmou: "Estava em patrulha pelo local dos fatos, conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, ocasião que viu um indivíduo do sexo masculino, sem camisa, segurando uma sacola plástica. Foi feita a abordagem do referido indivíduo, o qual

foi identificado como EDVAN ALCANTARA DOS SANTOS. Dentro da sacola que EDVAN segurava havia 225 invólucros contendo substância semelhante a cocaína, 75 unidades de substância semelhante a crack e 48 unidades de substância semelhante a maconha. Dentro da sacola também havia R\$ 58,00 e 1 aparelho celular. Em busca pessoal foi encontrada uma pedra de crack no bolso da bermuda de EDVAN. Diante dos fatos, trouxe EDVAN até esta delegacia para as providências de polícia judiciária". Em juízo afirmou: que ao entrar ao local visualizaram o réu com sacola plástica e em revista, havia droga nela; que o réu estava sozinho, mas afirmou que havia um indivíduo conhecido como "Gordo" e que teria deixado a sacola com ele; que havia valor em espécie na sacola também; que não conhecia o réu; que o local é dentro do cemitério e no momento o réu estava sozinho, sendo que, não deu tempo para fuga; que o depoente chegou na viatura; que o réu estava meio aéreo, aparentando ter consumido droga; que todo entorpecente estava na sacola plástica em poder do réu; que acha ter sido localizada pedra de crack no bolso do réu; que dinheiro e celular estavam na sacola, se não se engana, não sendo averiguado se o celular pertencia ao réu.

O réu EDVAN ALCÂNTARA DOS SANTOS em seu interrogatório na fase administrativa (fls. 10) afirmou: "Na presente data estava em um local onde iria comprar uma pedra de crack, pois é usuário, ocasião que um indivíduo conhecido pelo apelido de GORDO que estava com uma sacola cheia de drogas, pediu para o interrogado segurar a sacola com as drogas e repassa-la a uma pessoa que iria busca-la, sendo que GORDO deu uma pedra de crack ao interrogado em troca do 'serviço'. Pouco tempo depois a PM passou e capturou o interrogado. Afirma que não estava traficando drogas, pois somente é usuário e está morando na rua, sem endereço fixo há dois meses. Já foi preso anteriormente por tráfico e roubo. Não sabe o endereço de GORDO nem outras qualificações". Em juízo afirmou: que é de Cajamar/Jordanésia mas tinha separado da esposa e estava morando na rua, dormindo no cemitério de Morato; que não é alfabetizado, tendo estudado até 4a série; que vivia pela venda de papelão e caridade; que já foi preso por tráfico; que o dinheiro de R\$ 48 era proveniente do papelão; que no dia dos fatos tinha comprado uma pedra de crack no valor de R\$ 20,00 e próximo à abordagem tinha comprado mais uma pedra; que a sacola não estava com o réu, tendo o policial aparecido com ela; que o réu afirmou no momento que comprou o crack de um indivíduo "Gordo" que não sabe identificação; que não sabe ler ou escrever, não tendo lido o seu interrogatório policial; que a primeira pedra consumiu às 10:00 da manhã, sendo que, comprou a segunda, a colocou no bolso e logo na sequência houve a abordagem policial; que com o réu no momento da abordagem havia R\$ 8,00 e algumas moedas e uma pedra de crack; que entregou R\$ 20 reais e depois mais R\$ 20,00 para o Gordo; que confirma que passou o contato de Luana, sua ex-esposa, na Delegacia; que nega tenha recebido a sacola de Gordo para repassar para terceira pessoa, em troca de uma pedra de crack; que depois de ter assinado os papéis na delegacia que passou o contato da Luana; que ouvido novamente confirma que ninguém lhe entregou sacola; que na delegacia, após o réu afirmar que é usuário de drogas e que tinha uma pedra de crack em seu bolso que o policial em revista verificou que de fato o crack estava em seu bolso.

Certo é que as testemunhas apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos.

"Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório" (RJTJERGS 182/132).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Ainda há de se levar em conta que o acusado e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por

preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407).

Como visto, os depoimentos dos policiais são claros quanto à efetiva participação do réu no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, não bastam, por si só, para infirmá-las. Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos prestados pelos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

A sustentação da defesa de que o réu era usuário de drogas e que encontrava-se ali apenas para comprar crack não merece prosperar. Primeiro porque o réu se contradisse em seu depoimento na fase policial e em juízo ao afirmar primeiramente que: "... um indivíduo conhecido pelo apelido de GORDO que estava com uma sacola cheia de drogas, pediu para o interrogado segurar a sacola com as drogas e repassá-la a uma pessoa que iria buscá-la, sendo que GORDO deu uma pedra de crack ao interrogado em troca do 'serviço'". Posteriormente, em Juízo, afirmou: "...que no dia dos fatos tinha comprado uma pedra de crack no valor de R\$ 20,00 e próximo à abordagem tinha comprado mais uma pedra; que a sacola não estava com o réu, tendo o policial aparecido com ela"

Ainda a sustentação da defesa de que o réu encontrava-se drogado no momento da abordagem, sob efeito do crack e com comprometimento de sua capacidade volitiva e

cognitiva , que não leu seu depoimento na fase judicial também não merece respaldo. Se realmente tivesse no momento da abordagem com sua capacidade volitiva e cognitiva comprometida, não conseguiria afirmar em Juízo, com riqueza de detalhes, que: "comprou o crack de um indivíduo "Gordo" que não sabe identificação; que não sabe ler ou escrever, não tendo lido o seu interrogatório policial; que a primeira pedra consumiu às 10:00 da manhã, sendo que, comprou a segunda, a colocou no bolso e logo na sequência houve a abordagem policial; que com o réu no momento da abordagem havia R\$ 8,00 e algumas moedas e uma pedra de crack; que entregou R\$ 20 reais e depois mais R\$ 20,00 para o Gordo".

Nesta esteira, a versão do réu de que apenas encontrava-se no local para comprar drogas restou isolada diante do conjunto probatório realizado em juízo ou fora dele.

Ademais, importante frisar que, quanto ao ônus de prova, cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto.

Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado.

Neste sentido a defesa não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou indícios que roborassem o alegado.

A prova colhida leva à conclusão de que o réu estava vendendo substância entorpecente para terceira pessoa não encontrada e ainda que não estivesse efetivamente na venda, ficou demonstrado que estava com a sacola com o entorpecente e o dinheiro e se pretendia repassa-la para uma terceira pessoa a pedido de outro traficante, como afirmou na Delegacia, estaria igualmente inserido na cadeia do comércio ilícito de entorpecente.

Assim a versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se.

Portanto, demonstrado que o réu trazia a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha, crack e cocaína), a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico, os antecedentes infracionais e criminais do réu e, ainda, o depoimento das testemunhas de, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito: A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não

é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Desse modo, bem demonstrada se encontra a responsabilidade penal do réu pelo delito apontado na inicial, sendo de rigor a sua condenação. Em suma, demonstrado que o réu trazia consigo 48 (quarenta e oito) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 69,82g (sessenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas); 225 (duzentas e vinte e cinco) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 187,95g (cento e oitenta e sete gramas e noventa e cinco decigramas); e 76 (setenta e seis) porções de crack, com peso líquido aproximado de 12,16g (doze gramas e dezesseis decigramas),, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de comercialização.

Passo, pois, a dosagem da pena

1.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de crack, cocaína e maconha, entendo por exasperar a pena-base em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 110/116 e 118/120 (processo 0002429-14.2012.8.26.0197 que tramitou perante este Juízo da 2ª Vara da Comarca de Francisco Morato; 000243096.2012.8.26.0197 que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato), o que autoriza a exasperação da pena-base em 1/5. Assim considerando, resulta numa pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Anoto que: a Cocaína é substância entorpecente, altamente viciante que afeta o sistema neurológico e imunológico de forma irreversível, e, além de transformações internas, o uso constante causa uma degradação física evidente; no que se refere ao crack - especialistas classificam como a terceira droga mais prejudicial ao usuário, apesar de ser derivado da cocaína, o crack, pelo fato de ser consumido por meio de fumo tem seus efeitos ainda mais potentes e duram períodos mais curtos, o que gera o consumo de maiores quantidades; a heroína - é considerada como uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) isso pelo seu alto nível de vício e dependência, ademais, diminui a frequência cardíaca o que caracteriza grande riscos de o consumidor sofrer uma overdose. Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o autor é reincidente em crime doloso conforme observado às fls. 118 (processo 0001309-83.2017.8.26.0544, que tramitou perante este Juízo da 2ª Vara da Comarca de Francisco Morato) bem como praticou o delito durante a Pandemia da Covid-19, estando assim também presente a agravante do artigo 61, II, "j", razões pelas quais aumento a pena em mais 1/5, resultando em 8

anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 864 dias-multa.

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

C) Causas de aumento e de diminuição: Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, razão pela qual torno definitiva a pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 864 dias-multa. unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anoto que reconheço a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, bem como para afastar a incidência da diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, curvando-me à jurisprudência majoritária dos Tribunais. Nesse sentido: RHC 121598 / SP - SÃO PAULO; RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 21/10/2014; Órgão Julgador: Primeira Turma. Ainda, podemos citar: HC 363761/ TO HABEAS CORPUS 2016/0191886-0; Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181); Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 10/11/2016; Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2016.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 68/70). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Crim., Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Crim., Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

E) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

F) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena, especialmente pela reincidência do réu.

G) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena, especialmente pela

reincidência do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO SILVA JÚNIOR como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 61, II, "j" fixando-a em reclusão de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 864 dias-multa, unidade igual a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação.

Expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, ficando, nos termos do artigo 63 da Lei 11.340 decretada a perda da importância de R\$ 58,00 em favor da União, que deverá ser revertida diretamente ao Funad.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Francisco Morato, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA